

刑法
No.335

H21-17

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

【事例】

甲は、自動車のレンタル業を営む乙会社との間で、「返還期日は7日後とする。料金は返還と同時に支払う。」旨の約定で自動車1台を借りる契約を交わし、甲がこの契約を履行するものと信じた乙会社従業員から自動車1台の引渡しを受けた。

1. 甲は、前記契約締結の時点から既に自動車を返還期日に返還する意思を有していなかった。この場合、返還期日が経過しなければ甲に詐欺罪は成立しない。
2. 甲は、自動車の引渡しを受けた後、返還する意思を失い、返還期日経過後数週間にわたり通勤のため同車を使用していたところ、乙会社従業員が、直ちに同車を返還するよう強く要求したのに、これを拒否して上記同様に同車を使用し続けた。甲に横領罪は成立しない。
3. 甲は、自動車の引渡しを受けた後、同車の返還期日になって料金を支払う意思を失い、同日の朝、乙会社従業員が気が付かないうちに、借り受けた自動車を乙会社に返還し、そのまま料金を支払わずに行方をくらました。甲に刑法上の財産犯は成立しない。
4. 甲は、借り受けた自動車内で、同車を甲より前に借りた客の忘れ物である一万円札10枚を見付けたので、同車を返還する時に乙会社従業員に渡そうと考え、同車から持ち出して自ら保管していた。数日後、自動車を返還する際、甲は、前記10万円を持って同車で乙会社に赴いたが、同車を返還する間にその10万円を自分のものにしようと思い立ち、乙会社従業員に同車を返還し10万円は持ち帰った。甲に窃盗罪が成立する。
5. 甲は、借り受けた自動車を運転中、ハンドル操作を誤って同車を海に転落させ、これを水没させてしまったが、そのまま放置した。甲に横領罪が成立する。

No335	財産罪の成否	正答率
H21-17	正解 3	72%

1 誤っている

本記述では、詐欺罪（246条）の成立時期が問題となる。詐欺罪の成立要件は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③交付・処分行為、④財産上の損害、⑤これらが因果関係で包摂されていることである。このうち、欺罔行為とは、財物、財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れる行為をいう。本記述では、乙は甲が契約を履行するものと信じて甲との間で本件契約を締結しているので、甲が契約締結時に自動車を返還する意思を有していなかったのであれば、乙は本件契約を締結しなかったものと考えられる。したがって、乙は、自動車という財物の処分について錯誤を生じている。よって、甲が、自動車を返還する意思がないのに乙と契約を締結したことが欺罔行為に当たる。そして、詐欺罪は欺く行為を開始した時点で実行の着手が認められ、処分行為によって占有が移転した時に既遂となる。よって、本記述における甲には、乙から自動車の引渡しを受けた時に詐欺罪が成立する。

2 誤っている

本記述では、自動車の返還を拒絶したことが「横領した」といえるのか、横領罪（252条）における不法領得の意思の発現の有無が問題となる。横領罪の構成要件は①自己の占有する、②他人の物を、③横領することである。甲は①レンタル契約により引渡しを受けた②乙社の自動車について返還期日後に返還を拒んでいる。この点、判例は、不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の趣旨に反して所有者でなければできないような処分をする意思をいうものとしている。横領罪における横領行為とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいう。よって、所有者からの返還請求を拒絶するような事実上の処分行為も横領罪の横領行為に含まれることになる。本記述では、甲は、乙の所有物である自動車について、返還期日経過後に乙から返還を求められているにもかかわらず、それを拒否して自動車の利用を続けており、甲の行為は、所有者でなければできないような処分であるといえる。よって、甲は、不法領得の意思の実現する行為を行ったといえるので、横領罪が成立する。

3 正しい

本記述では、甲が自動車を借り受けたにもかかわらず、料金を支払っていないので、詐欺罪（246条2項）、横領罪（252条）、窃盗罪（235条）の成否が問題となる。この点、詐欺罪の成立要件は①欺罔行為、②相手方の錯誤、③交付・処分行為、④財産上の損害、⑤これらが因果関係で包摂されていることであるが、このうち、欺罔行為とは、財物、財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れる行為をいう。本記述では、甲は、ただ自動車を返還して行方をくらませただけであり、何ら乙に錯誤を生じさせるような行為を行っておらず、欺罔行為が認められない。よって、詐欺罪は成立しない。横領罪の成否についても、甲は乙の所有物である自動車を返還期日に乙に返還しており、横領行為が認められず、横領罪も成立しない。また、財産上の利益についての窃盗は不可罰であるので、甲が料金債務を免れたことは、窃盗罪を構成しない。よって、甲に刑法上の財産犯は成立しない。

4 誤っている

本記述では、窃盗罪（235条）における不法領得の意思、窃取行為の有無が問題となる。本記述において、甲は、客の1万円札10枚を自動車から持ち出して、自ら保管している。判例は、窃盗罪の主観的要件として、不法領得の意思を必要としている。そして、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用処分する意思であるとしている（最判昭26.7.13）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、使用窃盗、毀棄隠

匿罪との区別のために不法領得の意思が必要であるということを挙げている。本記述では、甲が1万円札10枚を自動車から持ち出して保管した時点において、甲は、前記10万円につき返還する意思を有していたのであるから、権利者を排除する意思が認められず、不法領得の意思はなく、窃盗罪は成立しない。また、甲は、自動車を返還する際に10万円を持ち帰っている。窃盗罪における窃取行為とは、占有者の意思に反して、自己又は第三者の占有に移す行為をいう。甲が10万円を自分の物にしようと思いついた時点においては、10万円につき、甲が同車から持ち出して自ら保管していたのであるから、甲に事実的支配が認められ、甲の占有に属しているといえる。したがって、本記述は、窃盗罪が成立するとしている点で、誤っている。

5 誤っている

横領罪（252条）における横領行為とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいうところ、本記述では、横領罪における不法領得の意思の有無が問題となる。この点、判例は、不法領得の意思につき、他人の物の占有者が委託の趣旨に反して所有権者でなければできないような処分をする意思をいうとしている。本記述では、甲は、借り受けた自動車を海に転落させ、水没させているが、これはハンドル操作を誤ってなされたものであり、不法領得の意思は認められない。また、その後、甲は、水没した自動車を放置しているが、自己の占有する他人の物を毀棄、隠匿する行為には、不法領得の意思が認められない。よって、本記述の甲に横領罪は成立しない。